

1503055-59.2020.8.26.0073

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Ana Luíza é conhecida pela prática do tráfico na cidade. Não se recorda se as rés praticavam o tráfico em associação mesmo residindo em casas separadas. Afirmou que a ré Ana Paula alegou que residia em Bauru e vinha para Avaré às vezes para se encontrar com a ré Joice. Respondeu que não tem conhecimento sobre a prática de tráfico por parte da ré Ana Paula, mas acha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503055-59.2020.8.26.0073 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503055-59.2020.8.26.0073

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2234789/2020 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 13730367 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2342/20/129

- DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2234789 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 2342/20/129 - DISE-

DEL.SEC.AVARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA LUIZA CERIACO DE PAULA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

ANA LUIZA CERIACO DE PAULA, JOICE DE FREITAS FRANCISCO e ANA PAULA BERTOZZI, já qualificadas nos autos a fls. 21, 22 e 23, foram denunciadas pelo Ministério Público como incursas nas sanções do artigo 33, "caput", e no artigo 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, porque

no dia 22 de setembro de 2020, por volta das 15h30min, na Rua Elza Moreira, nº 177, Bairro Gilberto Filgueiras, nesta Cidade e Comarca de Avaré, traziam consigo e tinham em depósito 12 (doze) porções de maconha, embaladas separadamente em material plástico transparente e branco, com uma massa líquida de 47,390g (quarenta e sete gramas e trezentos e noventa miligramas), 16 (dezesesseis) porções de cocaína, distribuídas em 14 pinos eppendorfs de plástico nas cores amarelo e rosa e duas porções embaladas em plástico transparente, com massa líquida de 4,080g (quatro gramas e oitenta miligramas) e 02 (duas) pedras de "crack", embaladas separadamente em plástico transparente, com massa líquida de 0,560g (quinhentos e sessenta miligramas), assim positivadas pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 145/150, drogas destinadas ao consumo de terceiros e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta ainda que, desde data incerta até o dia 29 de junho de 2020, neste dia por volta das 17h00min, nos locais supramencionados e em outros não especificados, as três rés associaram-se para o fim de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes.

Auto de prisão em flagrante e demais peças do inquérito fls. 01/180. As rés foram devidamente citadas (fls. 363, 365 e 379) e notificadas (fls. 246, 298 e 313) e, por meio de seus advogados constituídos (rés Joice e Ana Paula) e defensor público (Ana Luíza), apresentaram resposta à acusação (fls. 231/238, 300/307 e 317). A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2021 (fls. 318/320). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas três testemunhas de acusação e as rés interrogadas (fls. 380/381).

Em alegações finais, o Ministério Público discorreu sobre toda a prova produzida e, ao final, pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia (fls. 389/395). A douta defesa da ré Ana Luíza Ceriaco de Paula requereu a absolvição com fulcro no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena no patamar mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado e regime inicial aberto para cumprimento de pena, além da aplicação dos benefícios do artigo 44 do Código Penal ou, não sendo esse o entendimento, pela suspensão condicional da pena e, por fim, pleiteou seja assegurado o direito de recorrer em liberdade (fls. 398/411). A douta defesa da ré Joice de Freitas Francisco requereu a absolvição com fulcro no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena no patamar mínimo legal e reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 412/421). A douta defesa da ré Ana Paula Bertozzi requereu a absolvição com fulcro no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena no patamar mínimo legal e reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 422/431).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e Decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência de fls. 03/06, auto de exibição e apreensão (fls. 07/09), laudo de constatação provisória de entorpecente (fls. 10/15), fotografias (fls. 64/75), laudo químico-toxicológico de fls. 145/150, bem como por toda prova oral produzida em juízo.

A autoria delitiva foi devidamente elucidada por meio das provas carreadas aos autos e repousa, sem sombras de dúvida, sobre as rés.

A testemunha de acusação Alessandro Batista da Silva, Policial Militar, em juízo, informou que na data dos fatos, estavam em diligências para apurar um roubo ocorrido dias antes e souberam que o veículo usado na prática do crime estava na residência da ré Joice. Relatou que, durante diligência no local, verificaram a presença de objetos relacionados ao roubo na residência dela e da ré Ana Paula. Afirmou que, enquanto conduziam as rés Joice e Ana Paula ao plantão policial, viram a ré Ana Luíza que, assim que avistou a viatura policial, empreendeu fuga. Declarou que foram apreendidas drogas com a ré Ana Luíza e em sua residência. Respondeu que foram encontradas duas porções de crack com a ré Ana Paula. Disse que, quando da lavratura do flagrante das rés Joice e Ana Paula, no momento em que viu as sacolas

com tênis e balaclava dentro do imóvel, e nesse momento perceberam a ré Joice assustada vindo da cozinha, de onde se tem acesso ao quintal, e depois apareceu um vizinho delas em posse de drogas e uma balança de precisão, que tinham sido arremessadas pelo muro para ocultação durante a diligência da polícia na residência. Asseverou que a ré Ana Luíza confirmou a propriedade das drogas. Respondeu que as três rés tem amizade e que, no dia da ocorrência do roubo, a ré Joice e Ana Paula estavam esperando a ré Ana Luíza, que chegou correndo com balaclava cobrindo o rosto, entrou no veículo em que estavam as rés Joice e Ana Paula, tendo elas saído em fuga após o roubo. Declarou que a ré Ana Luíza é conhecida pela prática do tráfico na cidade. Não se recorda se as rés praticavam o tráfico em associação mesmo residindo em casas separadas. Afirmou que a ré Ana Paula alegou que residia em Bauru e vinha para Avaré às vezes para se encontrar com a ré Joice. Respondeu que não tem conhecimento sobre a prática de tráfico por parte da ré Ana Paula, mas acha que ela sabia porque convivia com a ré Joice. Contou que a ré Joice não admitiu a participação no tráfico, e disse que foram encontradas duas porções de crack com Ana Paula após busca pessoal. Respondeu que a ré Ana Luíza assumiu o tráfico de parte dela, sobre o entorpecente que foi com ela encontrado. Acrescentou que a ré Ana Luíza confessou aos policiais que havia participado do roubo com as rés Joice e Ana Paula, tendo entrado no carro delas e fugido, porém, a ré Ana Luíza não admitiu o tráfico em associação com as demais rés. Asseverou que a equipe policial logo que adentrou a garagem, avistou as roupas produtos de roubo, e logo que adentrou a sala, viu a arma de airsoft no sofá, e essa arma era de propriedade de Joice. Que foi possível ver a ré Joice voltando do quintal para a cozinha em direção à sala, e do quintal era possível arremessar os entorpecentes na casa do vizinho. Confirmou que colocaram as rés Joice e Ana Paula na viatura e, então, foram à busca de Ana Luíza. Disse que o imóvel das rés Joice e Ana Paula foi trancado, e não foi preciso ficar nenhuma viatura no local por não ter sido encontrado mais nada de ilícito lá. Relatou que o vizinho Bruno ligou para a polícia e então outra viatura fez contato com ele e foi encaminhado até delegacia onde foi constatado que a droga que foi arremessada em sua casa era referente à ocorrência envolvendo as rés. Esclareceu que, quando as duas porções de crack foram encontradas com a ré Ana Paula, ela alegou não ser usuária.

A testemunha de acusação Valdinei Ribeiro Pereira, Policial Militar, em juízo, prestou relato corroborando o depoimento de seu colega de farda. Acrescentou que tinha a informação de um roubo em que um veículo Citroen C4, na cor prata, com teto envelopado na cor preta. Relatou que localizaram o veículo estacionado na Rua Bastos Cruz e fizeram o contato, sendo atendido pela ré Ana Paula. Contou que questionaram sobre as roupas na garagem que seriam idênticas à da filmagem do roubo, sendo que era um tênis vermelho e umas roupas pretas. Que a ré Ana Paula respondeu que eram de uma amiga. Afirmou que do portão foi possível notar que havia uma arma no sofá, que depois constatarem ser uma arma de airsoft. Declarou que quando entraram, notou que a ré Joice veio da cozinha em direção à sala e, questionadas sobre o envolvimento na prática do roubo, as rés Joice e Ana Paula responderam que haviam dado carona à ré Ana Luíza. Respondeu que, quando entraram, não tinham avistado a ré Joice e ela veio da cozinha em direção à sala. Não viram ela com invólucros ou algum material na mão. Informou que a cozinha dá acesso a um quintal e esse quintal dá acesso às residências laterais, sendo que ela poderia arremessar alguma coisa para alguma casa por ali. Contou que, após essa diligência, conseguiram localizar Ana Luíza e, realizada a abordagem, foram localizadas algumas porções de maconha. Respondeu que Ana Luíza assumiu a participação no roubo, mas em relação às drogas assumiu apenas a posse das drogas que tinha com ela. Declarou que havia informações sobre duas mulheres que estavam praticando o tráfico de drogas na Rua Bastos Cruz, no cruzamento com a Rua Antônio Ferreira Inocência, mas não sabia quem eram as mulheres. Aduziu que, da casa de Ana Luíza, foram ao plantão policial para apresentar a ocorrência e lá tomaram conhecimento de que o vizinho de Joice e Ana Paula, chamado Bruno, foi até a Cia da Polícia relatar que viu policiais em uma casa vizinha à sua e então escutou um barulho em seu quintal e, ao verificar, viu uma sacola com várias coisas coloridas junto com uma balança de precisão e que não sabia o que era aquilo. Ato contínuo, uma equipe policial foi até a casa de Bruno

recolher os objetos que apareceram em seu quintal, levando-o até o plantão policial. Afirmou que se recorda de que tiveram o apoio de uma policial feminina que fez a revista nas três rés e foram encontradas duas porções de crack com a ré Ana Paula.

A testemunha de acusação Bruno Henrique Agostinho Doni, em juízo, relatou que chegou do trabalho e notou a presença das drogas e da balança de precisão em seu quintal. Contou que seu filho de cinco anos foi quem guardou os objetos. Respondeu que aqueles objetos poderiam ser arremessados por qualquer vizinho. Asseverou que ficou temeroso por alguma armação de alguém que não gostasse dele, então comunicou a polícia sobre os fatos. Declarou que tem uma casa entre a sua e a da ré Joice. Disse que praticamente não ficava em casa, sendo mais as suas crianças que ficavam lá. Esclareceu que os terrenos daquela região tem cerca de 8 metros e disse que acha possível que os objetos tenham sido arremessados da casa de Joice até sua casa.

A ré Joice de Freitas Francisco, em sede de interrogatório judicial, negou os fatos. Afirmou que desconhece as drogas e que elas não lhe pertencem. Alegou que nunca usou drogas. Respondeu que via Ana Paula a cada quinze dias e desconhece se ela usava drogas. Contou que a casa onde morava era alugada e pagava o aluguel por meio de seu trabalho no Uber e às vezes sua irmã também lhe enviava dinheiro quando precisava. Disse que conhece Ana Luíza do kung fu, também jogava futebol junto, e perdeu o contato, até que ela a viu trabalhando como Uber, e desde então ela lhe pediu para fazer algumas corridas. Acrescentou que estava em sua casa por volta de 11h30min, pois havia acabado de buscar Ana Paula na frente do Saladão Max às 10h, então às 11h30min os policiais bateram à sua porta, momento em que estava lavando louça e pediu para Ana Paula que atendesse. Afirmou que Ana Paula foi e gritou da porta falando que eram policiais, ao que lhe respondeu que poderia abrir. Relatou que os policiais foram até a cozinha e perguntaram-lhe onde estava no dia anterior, ao que respondeu onde estava. Contou que os policiais perguntaram se a depoente poderia levá-los até o local onde havia deixado a moça que estava consigo, o que foi feito. Aduziu que, quando chegou lá, os policiais conversaram um pouco com ela e depois voltaram até a casa da depoente, onde ficaram por cerca de 20 minutos a meia hora e em seguida foram até a delegacia. Negou ter jogado alguma coisa pelo muro. Respondeu que a ré Ana Luíza era usuária de drogas. Declarou que levou os policiais até a casa de Ana Luíza, mas não viu os policiais achando a droga, pois os policiais pularam, arrombaram a porta da sala, retiraram a ré Ana Luíza e voltaram para sua casa, e foi tudo muito rápido. Contou que era muito raro a ré Ana Luíza ter acesso à sua casa.

A ré Ana Paula Bertozzi, em sede de interrogatório judicial, afirmou que mora em Bauru e vinha para Avaré quinzenalmente para visitar a ré Joice. Declarou que só usou drogas após perder os pais e brigar com Joice, mas não usa mais. Negou as acusações de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegou que não sabia de drogas. Aduziu que quando abriu o portão, os policiais estavam verificando suposta participação em uma ocorrência de roubo, e nesse momento Joice estava lavando a louça. Negou que Ana Luíza frequentasse a casa de Joice. Negou conhecer Ana Luíza. Negou ter visto o momento em que a polícia teria abordado e prendido Ana Luíza. Disse que ficou dentro do carro da polícia na hora que foram levadas para a delegacia. Acrescentou que foram até a casa de Ana Luíza na viatura, onde Ana Luíza foi abordada e colocada dentro da viatura, de onde foram todos para a delegacia. Respondeu que não usa mais drogas e não tem ido a Avaré, pois não está mais com a ré Joice. Relatou que trabalha na mesma empresa há quatro anos e subiu de cargo. Alegou que, na viatura, foi do lado do passageiro, e a Joice foi atrás, mas em nenhum momento os policiais lhes deram voz de prisão. Afirmou que só na revista na delegacia é que foi encontrada a droga. Respondeu que não conhece Ana Luíza. Contou que nunca viu nenhuma movimentação ilícita na casa de Joice, e disse que ela não usava drogas. Informou que Joice trabalhava vendendo roupas e tênis.

A ré Ana Luíza Ceriaco de Paula, em sede de interrogatório judicial, afirmou que estava praticando o tráfico sozinho. Contou que praticou o roubo e chamou a ré Joice para uma corrida de Uber. Relatou que, no calor da emoção, deixou drogas na casa de Joice e ela não sabia que as drogas tinham sido deixadas ali. Disse que

pagou para Joice ir e voltar de Uber, mas não falou que ia receber de uma pessoa para pagar o aluguel, e Joice não sabia de nada. Respondeu que frequentava a casa de Joice em um churrasco ou outro porque seu pai é amigo dela. Afirmou que a droga encontrada na casa do vizinho Bruno era de sua propriedade.

Com efeito, as negativas oferecidas pelas rés Joice e Ana Paula e a versão apresentada pela ré Ana Luíza soam por demais inconvincentes e completamente desamparadas de um mínimo de suporte indiciário e credibilidade, cujo único intuito é o de eximi-las das graves imputações de tráfico. Quanto à acusação de associação para o tráfico, o conjunto probatório se revela insuficiente para a condenação. Pois bem, a tipificação do crime de tráfico de drogas, in casu, extrai-se das circunstâncias da prisão, da quantidade e variedade de droga apreendida (12 (doze) porções de maconha, embaladas separadamente em material plástico transparente e branco, com uma massa líquida de 47,390g (quarenta e sete gramas e trezentos e noventa miligramas), 16 (dezesesseis) porções de cocaína, distribuídas em 14 pinos eppendorfs de plástico nas cores amarelo e rosa e duas porções embaladas em plástico transparente, com massa líquida de 4,080g (quatro gramas e oitenta miligramas) e 02 (duas) pedras de "crack", embaladas separadamente em plástico transparente, com massa líquida de 0,560g (quinhentos e sessenta miligramas) e de instrumento apreendido para fracionamento e distribuição da droga (balança de precisão).

Desse modo, as alegações das rés, em cotejo com a prova oral acusatória, mostraram-se contraditórias, pouco convincentes e sucumbiram perante os relatos firmes, minuciosos e convincentes das testemunhas de acusação sobre a posse e venda de drogas. Não merece valor probatório superior ao dos servidores públicos, que não tinham relação de afeto ou ódio com as rés e estavam comprometidos com a preservação da ordem pública e com a defesa do interesse da sociedade. Não se olvide que o parágrafo único do artigo 186 do Código de Processo Penal, adotando o princípio do nemo tenetur se detegere, previsto na Constituição Federal, determina que o silêncio do acusado não poderá ser considerado em seu desfavor em processo criminal, todavia, as inverdades por elas proferidas em interrogatório judicial constituem-se em mais um elemento a ser considerado pelo Magistrado no momento da formação de sua convicção. Nesse sentido, ponderou o Eminentíssimo Desembargador José Raul Gavião de Almeida que: "...se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a inverdade..." (TJSP, 6ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.10.390742-6, Voto nº 10.943)(g.n.). De maneira diversa, em depoimento uníssono entre si e ao informe prestado na delegacia, os policiais confirmaram em juízo a dinâmica da prisão. Suas declarações foram, em essência, coerentes e harmônicas. É de se asseverar que o simples fato das testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais ou agentes públicos em geral, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são eles aptos, como qualquer cidadão, a presar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento somente procede quando decorrente de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não se evidenciou nestes autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao

depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.)

Considere-se ainda que, em casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela qual desprezar os depoimentos policiais nesses casos implicaria em consagrar a total impunidade. Não há como crer que cada policial forjou flagrante e prestou falso testemunho. A despeito das ponderações da zelosa defesa, despontaram fartas evidências de que as drogas em poder das rés tinham como objetivo destiná-las a terceiros.

Além dos depoimentos dos policiais, o fato de o vizinho da ré Joice, sr. Bruno, ter prestado depoimento informando que encontrou drogas e balança de precisão em sua casa, sendo que os terrenos daquela localidade tem cerca de oito metros de largura, leva à conclusão de que é possível arremessar objetos de forma a superar a distância que havia entre as casas de Joice e de Bruno.

De outra feita, as defesas das rés não conseguiram explicar e não lograram êxito em refutar as assertivas minuciosas dos depoentes, além de não arrolarem testemunhas que amparassem suas ressalvas. Não indicaram motivos concretos e plausíveis para falsa incriminação. Não demonstraram vício no flagrante e no resultado da persecução. Entretanto, a dúvida persiste quanto à associação para o tráfico, posto que não ficou perfeitamente provado o vínculo e a atividade com tarefas definidas e organizadas que configurem o delito, parecendo, nesse feito e com as provas aqui amalhadas, apenas um concurso de pessoas na prática do tráfico.

De mais a mais, a versão dada pela ré Ana Luíza, alegando que é proprietária das drogas e balança de precisão encontradas na casa de Bruno, vizinho da ré Joice, unida ao argumento de que a ré Joice não tinha conhecimento de que Ana Luíza teria deixado as drogas em sua casa por descuido, são absolutamente desprovidas de credibilidade, pois a ré Joice não teria se preocupado em atirar a droga para outra residência se não soubesse que Ana Luíza as teria esquecido ali. As alegações da ré Joice também se revelam carentes de credibilidade, pois conflitam com as alegações da ré Ana Luíza e com todo o conjunto probatório coligido aos autos. Neste ponto ressalto que, embora a ré Ana Paula tenha alegado que as duas porções de crack encontradas consigo eram destinadas para uso próprio, o fato de, eventualmente, usar drogas, não retira a convicção de que também traficaria. Uma conduta não exclui a outra. Na verdade, é usual, entre usuários e viciados em drogas, o tráfico como forma de viabilizar o sustento do vício. Bem típica a conduta, pois, que merece severa punição.

Além disso, como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente, pois o tipo penal inserto no artigo 33 da lei antidrogas fez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "ter em depósito" e "trazer consigo". Confira-se:

"Anoto, ainda, que para configuração do crime do artigo 33, da Lei de Drogas imputado aos réus, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que os agentes tragam consigo, tenham era depósito ou guardem a substância entorpecente, não se exigindo a traditio, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512)"

(9174718-08.2009.8.26.0000, Rel. Marco Antonio Marques Maia, 6ª Câmara de Direito Criminal, 17/09/2009)" (grifo nosso).

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663) (grifo nosso)

Assim, com relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, o conjunto probatório não foi sólido o suficiente para comprovar que as rés mantinham o vínculo associativo necessário para configurar tal delito, inclusive porque o objeto da investigação, inicialmente, era relativo à ocorrência de roubo, e as

drogas e balança de precisão foram encontradas durante a diligência.

Desta feita, o Ministério Público trouxe aos autos provas idôneas que demonstraram que as rés praticavam o tráfico de drogas, sendo de rigor a condenação em relação ao crime do artigo 33 da Lei de Drogas, além da absolvição em relação ao crime previsto no artigo 35 do mesmo diploma em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO as rés ANA LUÍZA CERIACO DE PAULA, JOICE DE FREITAS FRANCISCO e ANA PAULA BERTOZZI, qualificadas nos autos, como incursas nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Por outro lado, ABSOLVO as rés ANA LUÍZA CERIACO DE PAULA, JOICE DE FREITAS FRANCISCO e ANA PAULA BERTOZZI, qualificadas nos autos, da imputação que lhes foi feita como incursas no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Resta dosar a pena pelo critério trifásico adotado pelo Código Penal.

Em relação à ré ANA LUÍZA CERIACO DE PAULA:

Na primeira fase, sopesadas os elementos preconizados pelo artigo 42 da lei de Drogas e do art. 59 do Código Penal, considerando a diversidade e quantidade de droga apreendida, a conduta de tentar ocultar a droga, a personalidade e comportamento social revelados pelos registros criminais (F.A. a fls. 338/344 e certidões a fls. 345/348) os quais não devem ser ignorados, como se ser processado e jamais ter mácula na folha de antecedentes sejam situações idênticas, em detrimento da isonomia substancial, bem como da personalidade voltada à delinquência, observo que a ré possui péssimos antecedentes. Assim, reputo razoável elevar a pena-base em 1/5 (um quinto), o que perfaz 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase de aplicação de pena, verifico que a ré é reincidente (fls. 346 – proc. 3007165-71.2013.8.26.0073), razão pela qual aumento a pena anteriormente fixada em mais 1/6 (um sexto), atingindo 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Não estão presentes quaisquer outras circunstâncias atenuantes e/ou agravantes. Na terceira fase, inaplicável a minorante do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, eis que a quantidade e variedade de entorpecente apreendida indica que a ré dedicava-se ao tráfico com certa frequência e, além disso, a ré é reincidente. Contemple-se que é inviável a concessão do benefício quando, sopesados a quantidade de entorpecente e sua nocividade a indicar tratar-se de profissional desse mercado nefasto. A este teor: "Tráfico de drogas praticado sob a vigência da Lei 6.368/1976. Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Paciente que se dedicava à atividade criminosa. Para que a redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 seja concedida, não basta que o agente seja primário e tenha bons antecedentes, sendo necessário, também, que ele não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. O voto do eminente Min. Felix Fischer, relator do habeas corpus ora questionado, muito bem explicitou o motivo pelo qual não foi possível a aplicação daquele benefício ao paciente, ressaltando que 'o tribunal a quo negou provimento ao recurso defensivo, a uma, por entender que o paciente se dedicava a atividade criminosa, fazendo do comércio de drogas seu meio de vida, a duas, porque a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 só se aplicaria àquele que como fato isolado vende substância entorpecente, a três, tendo em vista que a sua aplicação é restrita às condenações ocorridas com base na Lei 11.343/2006, não se podendo, assim, a pretexto de se aplicar a lei mais benéfica, combinar partes diversas das duas normas, porquanto isso implicaria, em última análise, na criação de uma terceira lei.'" (STF RHC 94.802 Rel. Min. Menezes Direito j. 10.02.09 - DJE 20.03.09). E nem se alegue possível bis in idem relativo ao aumento da pena pelos maus antecedentes e a não aplicação do aludido redutor, uma vez que este deixou de incidir também em virtude da dedicação às práticas delitivas, tudo em fases distintas da dosimetria. Confira-se: "A valoração da reincidência na segunda etapa da dosimetria, como circunstância agravante, não é incompatível com a sua

utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Precedentes" (HC 214069/SP - Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - DJe 29/11/2013). De igual modo, inexistentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição passíveis de alterar a pena, fixo em definitivo a pena de 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, com o dia unitário no piso mínimo legal.

Diante do montante da pena e do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº 8.072/90, a ré Ana Luíza Ceriaco de Paula deverá iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO. Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja, finalmente, porque o art. 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, são expressos ao proibir referido benefício. Filio-me ao entendimento que sustenta a constitucionalidade de tais dispositivos, pelas seguintes razões, algumas delas retiradas da Arguição de Inconstitucionalidade no HC 120.353-SP, julgada em 04.11.2009 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Rel. originário Min. Og Fernandes, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler: i) o art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, determina que a lei regulará a individualização da pena; ii) o art. 5º, inciso XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inciso LI, o qual autoriza a extradição de brasileiro naturalizado comprovadamente envolvido com tráfico de drogas; iii) é perfeitamente possível que o legislador ordinário proíba a substituição da pena por restritiva de direitos, tanto que o art. 44, do CP, veda o benefício para todos os crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou com pena superior a 04 anos, ou, ainda, no caso de ser o agente reincidente em crime doloso; iv) o Brasil assinou tratados internacionais se comprometendo a combater o tráfico de drogas; v) o crime de tráfico de drogas, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no art. 44, III, do CP, além de verdadeira sensação de impunidade nesta pequena e interiorana cidade de Avaré.

Em relação à ré JOICE DE FREITAS FRANCISCO:

Na primeira fase, sopesados os elementos preconizados pelo artigo 42 da lei de Drogas e do art. 59 do Código Penal, verifico que a ré é primária (F.A. a fls. 353/354 e certidões a fls. 355/356), e por isso fixo a pena-base no valor mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase de aplicação de pena, estão ausentes quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. Na terceira fase, entendo que se faz necessário o reconhecimento da diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois a ré é primária e não há nos autos notícias de sua participação em associação criminosa. Assim, diminuo a pena anteriormente imposta em 2/3 (dois terços), resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Não estão presentes mais causas de aumento ou de diminuição da pena. Portanto, fixo em definitivo a pena a cumprir de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e PAGAMENTO DE 166 (cento e sessenta e seis) DIAS-MULTA, com o dia unitário no piso mínimo legal.

Pese contrário ao entendimento deste Magistrado, necessário apontar que o regime inicial em relação à ré Joice de Freitas Francisco deverá ser o ABERTO, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do HC n.

596603-SP, no qual houve determinação para imposição de regime inicial aberto para cumprimento de pena, inclusive em relação a fatos futuros, na hipótese de condenação por tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Confira-se (...) Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena. (STJ - HC: 596603 SP 2020/0170612-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04/08/2020).

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal - HC 118.533 - reconheceu que o delito em questão não é mais hediondo, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Desta forma, faço a substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas restritivas de direitos. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de Prestações de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, por se revelarem as mais adequadas ao caso, sendo aquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo da condenação, junto a entidade determinada pelo juízo da execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, sem prejuízo da multa já fixada e a prestação pecuniária no valor de um terço do salário mínimo nacional da época da infração penal, sendo destinada para entidade beneficente também indicada pelo juízo das execuções penais.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, caberá fiscalizar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar da condenada, consoante disposto pelo artigo 150 da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que a condenada é facultada cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55 do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante.

Em relação à ré ANA PAULA BERTOZZI:

Na primeira fase, sopesados os elementos preconizados pelo artigo 42 da lei de Drogas e do art. 59 do Código Penal, verifico que a ré é primária (F.A. a fls. 349/350 e certidões a fls. 351/352), e por isso fixo a pena-base no valor mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase de aplicação de pena, estão ausentes quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. Na terceira fase, entendo que se faz necessário o reconhecimento da diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois a ré é primária e não há nos autos notícias de sua participação em associação criminosa. Assim, diminuo a pena anteriormente imposta em 2/3 (dois terços) resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Não estão presentes mais causas de aumento ou de diminuição da pena. Portanto, fixo em definitivo a pena a cumprir de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e PAGAMENTO DE 166 (cento e sessenta e seis) DIAS-MULTA, com o dia unitário no piso mínimo legal.

Pese contrário ao entendimento deste Magistrado, necessário apontar que o regime inicial em relação à ré Ana Paula Bertozzi deverá ser o ABERTO, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do HC n. 596603-SP, no qual houve determinação para imposição de regime inicial aberto para cumprimento de pena, inclusive em relação a fatos futuros, na hipótese de condenação por tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Confira-se (...) Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de

cumprimento da pena. (STJ - HC: 596603 SP 2020/0170612-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04/08/2020).

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal - HC 118.533 - reconheceu que o delito em questão não é mais hediondo, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Desta forma, faço a substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas restritivas de direitos. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de Prestações de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, por se revelarem as mais adequadas ao caso, sendo aquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo da condenação, junto a entidade determinada pelo juízo da execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, sem prejuízo da multa já fixada e a prestação pecuniária no valor de um terço do salário mínimo nacional da época da infração penal, sendo destinada para entidade beneficente também indicada pelo juízo das execuções penais.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, caberá fiscalizar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar da condenada, consoante disposto pelo artigo 150 da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que a condenada é facultada cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55 do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante.

De acordo com o artigo 387, parágrafo único do CPP, inalterados os requisitos e não existindo prisão provisória decretada, as rés poderão apelar em liberdade.

Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreto o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente, adotem-se as seguintes providências: (a) expeça-se guia de execução (definitiva, se o caso) dos condenados; (b) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686, do Código de Processo Penal; (c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando sua condenação, com a devida identificação deles, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição da República c/c o art. 71, §2º, do Código Eleitoral; (d) oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; (e) efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei.

P.I.C.

Avare, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA